

1500172-61.2022.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico. Senão vejamos. Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, a materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500172-61.2022.8.26.0626

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083374/2022 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 23874619 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 1105/22/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2083374 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

YURI LOPES DOS SANTOS e outro

Data da Audiência:

20/10/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 20 de outubro de 2022, às 13 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Yuri Lopes dos Santos (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros e Yurica Lopes dos Santos (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Charles Henrique Ribeiro, OAB 268716/SP. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Thiago Aparecido de Souza e Douglas Rodrigues Bittencourt da Costa. Presentes as testemunhas da defesa, a saber: Marta Nilza Alves da Silva e Flávia Aparecida Conceição.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram

colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Thiago Aparecido de Souza e Douglas Rodrigues Bittencourt da Costa, a seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas da defesa, Marta Nilza Alves da Silva e Flávia Aparecida Conceição, finalmente foram realizados os interrogatórios dos acusados. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada palavra ao Ministério Público, pelo "Parquet" foi dito que desistia da realização de exames periciais grafotécnico e dos celulares apreendidos; dada palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha Beatriz Ferreira Santos. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do Ministério Público quanto à realização de exame pericial nos celulares apreendidos e grafotécnico; homologava, ainda, a desistência da Defesa quanto a oitiva da testemunha Beatriz Ferreira Santos. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. YURI LOPES DOS SANTOS e YURICA LOPES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, c.c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 26 de março de 2022 e até a referida data, YURI LOPES DOS SANTOS e YURICA LOPES DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas. Consta, ainda, que no dia 26 de março de 2022, às 01h20min, na Avenida Dr. Emiliano Campideli, nº 01, Olaria, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, YURI LOPES DOS SANTOS e YURICA LOPES DOS SANTOS, previamente associados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 72 (setenta e dois) tijolos de Maconha, com peso total de 56.000g, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Constatação Preliminar juntados aos autos. A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2022 (fls. 105/108). Os réus foram citados (fls. 126 e 128), e apresentaram resposta à acusação (fls. 133/136 e 140/141). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum, bem como foi realizado o interrogatório dos réus, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Encerrada a instrução criminal, na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A ação é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico. Senão vejamos. Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, a materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fl. 17), auto de constatação preliminar (fl. 18), laudos periciais que confirmam a natureza das substâncias apreendidas e demais provas produzidas nos autos. A autoria delitiva, também, restou demonstrada e caracterizada nos autos. A testemunha e policial THIAGO APARECIDO DE SOUZA, na delegacia, disse que na data dos fatos, estava em serviço junto ao seu parceiro de farda SD Bittencourt, por volta das 19:31h, quando receberam uma denúncia anônima de nº 15214, via Copom, com o seguinte assunto: "tráfico de drogas na Avenida Dr. Emiliano Campideli, nº 01, Bairro: Olaria, aproximadamente 30 metros da Creche CEI Olaria. Que realizaram patrulhamento pelo local, por volta das 01h20min, e visualizaram o indivíduo identificado como YURI LOPES DOS SANTOS, este, ao perceber a presença da viatura correu e adentrou a residência (local dos fatos), motivo pelo qual foi realizado o acompanhamento do indivíduo. No interior da residência, além de Yuri, havia mais três crianças H.G.

dos S.G de 7 (sete) anos de idade, A.L. dos S.S de 3 (três) anos de idade e T. de 3 (três) anos de idade, filho de Flavia, uma conhecida.; que no interior da residência foi percebido pelos policiais militares um forte odor de substância entorpecente e indagado acerca de forte cheiro de maconha, a pessoa de YURI admitiu aos policiais que havia uma caixa no quarto de YURICA, sua irmã, contendo a droga. De posse da informação, foram realizadas buscas pela residência, onde, além da caixa apontada por YURI, também foram localizadas, em cima do guarda roupas no mesmo quarto, mais duas caixas cheias da mesma substância. Que também encontraram um envelope com selo dos Correios, contendo a contabilidade do tráfico e diversas folhas soltas também os mesmos tipos de anotações. Que em seguida YURICA chegou ao local, acompanhada de sua amiga Flavia, que havia ido buscar o filho. Diante disso, foi dada voz de prisão a YURI e YURICA, que foram conduzidos ao Distrito para os procedimentos de polícia judiciária. EM JUÍZO, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial DOUGLAS RODRIGUES BITTENCOURT DA COSTA, que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega. A testemunha de defesa FLAVIA APARECIDA CONCEIÇÃO. EM JUÍZO, disse que estava com a ré no dia da sua prisão. Sairam de casa para comprar cerveja em uma adega. Quando voltaram para casa, os policiais já estavam lá. Não entrou na casa durante a abordagem policial. Sabe que a ré foi presa por drogas, mas não sabe se ela tem envolvimento com o crime. A ré trabalhava no UPA. A testemunha de defesa MARTA NILZA ALVES DA SILVA, EM JUÍZO, disse que a ré é uma pessoa trabalhadora e pelo que sabe não tem envolvimento com o crime. Em seu interrogatório policial, o réu YURI LOPES DOS SANTOS, na delegacia, manifestou o desejo constitucional de permanecer calado. EM JUÍZO, confessou que estava guardando o entorpecente apreendido em sua casa. A ré não sabia desta droga e não tem envolvimento com o crime. Em seu interrogatório policial a corré YURICA LOPES DOS SANTOS, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. EM JUÍZO, negou a prática do crime. Disse que não sabia que o réu estava guardando entorpecente em sua casa. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar somente o réu Yuri pela prática do crime de tráfico. Isto porque, as declarações dos policiais militares foram coesas desde a fase inquisitiva. Além disso, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a dinâmica da abordagem, o comportamento do acusado logo antes da apreensão, a quantidade de drogas, bem como a confissão do réu demonstram a autoria delitiva. Inicialmente, afasto a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio dos acusados. Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em solo policial quanto em juízo, infere-se que estes adentraram à residência do acusado Yuri pautados por fundadas razões que levavam a presumir a configuração de flagrante delito de tráfico de entorpecentes. Isto porque, além das denúncias anônimas recebidas via COPOM, o acusado, ao avistar a viatura correu para dentro do imóvel. Como se sabe, em situações de flagrante delito como ocorre no caso de armazenamento de entorpecentes em residência, tendo em vista que o tráfico é crime permanente o ingresso das forças policiais no imóvel apenas será lícito se houver fundadas razões que corroborem, a priori, seu entendimento de que, no interior da residência pratica-se um crime. Entendo que, no presente caso, estavam presentes as fundadas razões acima mencionadas, tendo em vista que, em todas as ocasiões em que ouvidos, os policiais militares, em uníssono, confirmaram que o acusado correu de volta para o imóvel tão logo os avistou. Sendo assim, a soma da informação fornecida via COPOM à atitude suspeita do acusado Yuri, constitui cenário fático excepcional, que corroborava as suspeitas dos agentes de segurança quanto à presença de ilícitos no interior da residência. Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido já se pronunciaram o E. STF, bem como o Colendo STJ: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é

aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)

para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido". (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, os acusados estavam em posse de grande quantidade de entorpecentes no interior da residência vistoriada. No mais, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu

testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, litteris: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). E mais, diante da prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, são capazes de apontarem fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidarem o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazerem a certeza do cometimento imputado, especialmente quando as versões por eles descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante e não desmerecida no contraditório. Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudica-lo, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que os réus traziam consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Quanto a ré, não restou devidamente comprovada a autoria, sendo de rigor a sua absolvição. Nota-se que o réu confessou que estava guardando o entorpecente, mas ressaltou que a sua irmã não sabia da existência destas drogas. Ademais, os policiais não conseguiram relatar o envolvimento da ré. O que poderia afastar a dúvida sobre a autoria da ré seria a realização de exame grafotécnico nas anotações apreendidas e a perícia no celular apreendido. Contudo, o Ministério Público desistiu destas provas, tornando insanável a dúvida sobre a participação da ré. A respeito ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018). E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras

palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel.

Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo crime de associação ao tráfico de drogas à corré". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021). Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre os réus. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe. Por fim, de rigor a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, vez que os relatos dos policiais foram robustos a indicar que a prática delitiva se deu a aproximadamente 30 metros da Creche CEI do bairro Olaria. O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que os acusados tinham em sua posse os entorpecentes e munições descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria: Réu YURI LOPES DOS SANTOS: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, ante o disposto na súmula nº 444 do STJ, não verifico a presença de elementos capazes de alterar a pena-base, razão pela qual esta deve ser estabelecida no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Anoto que a condenação relativa ao processo nº 1501827-21.2019.8.26.0126 (certidão de fl. 188) possui trânsito em julgado para a defesa com data posterior aos fatos aqui apurados (14/06/2022), logo, inviável utiliza-la para fins de reincidência. Assim, mantenho as penas

inalteradas nesta etapa em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Tendo em vista a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, razão pela qual elevo a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo regime FECHADO para ambos os acusados, tendo em vista a pena fixada, a gravidade em concreto do delito, considerando quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como em razão da reincidência do acusado YURI LOPES. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: "A quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", e 44 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em mais de 4 e menos de 8 anos (5 anos de reclusão), a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (441 gramas de maconha, 10,1 gramas de cocaína e 12,6 gramas de crack) justificam a necessidade da imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado." (STJ, AgRg no Ag em RESp 1.682.761, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.08.2020). Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: 1) CONDENAR o réu YURI LOPES DOS SANTOS à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. 2) ABSOLVER a ré YURICA LOPES DOS SANTOS da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3) ABSOLVER ambos os réus da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado da ré YURICA LOPES DOS SANTOS. Quanto ao réu, presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito do réu recorrer em liberdade. Isto porque, foi condenado a elevada pena pela prática de crime equiparado a hediondo, não sendo razoável conceder a liberdade neste momento. Recomendem-se aos locais em que se encontram recolhidos. DECRETO o perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad. VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca

do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público e pela Defesa da corréu Yurica Lopes dos Santos foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença. Pela defesa do corréu Yuri Lopes dos Santos foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EtjkeuHjAL5BlFHfzrKrK7oBxSK6MaRJG2JNSgufzTIFQQ?e=cPT4qv